

1500543-36.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... (art. 301 do CPP), sendo que o tráfico de drogas é delito permanente. Os agentes da guarda municipal realizaram a abordagem após receberem a informação via rádio de que um indivíduo com características semelhantes ao do acusado realizava o tráfico de drogas no local. Neste contexto, é legítima a busca pessoal e a prisão em flagrante realizada pela guarda municipal, quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500543-36.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500543-36.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2262229/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 20472436 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2650/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2262229 - DEL.POL.SALTO, 2650/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO MELO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu ADRIANO MELO DA SILVA, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06 c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal. porque, em tese, no 24 de setembro de 2021, por volta das 20h12min, na Rua Etiópia, nº 93, Jardim das Nações II, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, o acusado, trazia consigo e guardava para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 15 (quinze) porções de "cocaína", acondicionadas em microtubos plásticos, com peso líquido de 6,65g (seis gramas e sessenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo

com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 04 de fevereiro de 2022 (fls. 88-92).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 123-137).

A denúncia foi recebida em 31 de maio de 2022 (fl. 149-152).

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas comuns.

O pedido de análise de proposta de ANPP e as preliminares de inépcia da denúncia e ilegalidade de atuação da Guarda Municipal foram apreciados e indeferidos pela decisão de fls. 149-152, que transitou em julgado.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e, subsidiariamente, que se reconheça a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da referida lei.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Não há qualquer mácula na atuação dos agentes públicos, qualquer do povo pode realizar e os agentes devem efetuar a prisão em flagrante (art. 301 do CPP), sendo que o tráfico de drogas é delito permanente. Os agentes da guarda municipal realizaram a abordagem após receberem a informação via rádio de que um indivíduo com características semelhantes ao do acusado realizava o tráfico de drogas no local. Neste contexto, é legítima a busca pessoal e a prisão em flagrante realizada pela guarda municipal, quando verificada a situação de flagrância, precedida de justa causa para a revista pessoal. Na mesma linha de entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.

NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS.

SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. USO DE DROGA NO MOMENTO DA

ABORDAGEM. BUSCA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO FRANQUEADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO IMPROVIDO. 1. Considera-se lícita a revista pessoal executada por guardas municipais, com a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Configurada a situação de flagrância, com a demonstração de fundada suspeita, não se verifica ilegalidade na realização de abordagem pessoal por guardas municipais que estavam em patrulhamento com cães farejadores, encontrando drogas com o paciente e nas proximidades do local do flagrante, pois o acusado informou que estava usando drogas no momento em que foi abordado. 3. A questão referente à aplicação da minorante, a matéria já foi analisada no HC 563.700/SP, tratando-se de mera reiteração de pedido. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 597923 SP 2020/0176108-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)".

Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilícitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômulo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da

conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021).

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 07-09), auto de exibição e apreensão (fl. 10-11), auto de constatação preliminar (fls.12) e laudo de exame químico toxicológico (fls.73-75) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais Antônio Alessandro Frois e Regis Conceição, em síntese, relataram que estavam em patrulhamento foram informados via controle de que um indivíduo branco trajando camiseta azul e bermuda jeans estaria realizando tráfico de drogas na rua Etiópia. No local, viram um indivíduo parado no meio da via com as características descritas o qual ao perceber a presença da viatura passou a caminhar. Realizada abordagem e revista pessoal, no bolso traseiro direito foram encontrados 15 microtubos contendo cocaína, no seu bolso dianteiro esquerdo uma cédula de R\$ 50,00 reais e na capinha de seu celular mais R\$ 250,00 reais.

Indagado, confessou que estava no local realizando a venda de entorpecentes, contudo informou que os R\$ 250,00 era do auxílio emergencial e R\$ 50,00 reais provenientes do tráfico de drogas.

O réu, interrogado judicialmente, em resumo, confessou a prática do crime.

Os guardas apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu guardava e trazia consigo 15 (quinze) porções de "cocaína", acondicionadas em microtubos plásticos, todas individualmente embaladas e prontas para entrega a consumo e fornecimento a terceiros.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, certo é que as circunstâncias da prisão, em conformidade com a denúncia anônima, aliadas à apreensão de dinheiro e à existência de mensagem no telefone celular do acusado relacionada ao tráfico de drogas (fl. 82) e, corroborados pelos demais depoimentos colhidos em Juízo, são suficientes a embasar o decreto condenatório.

O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal, afastando, assim, a tese de posse para consumo próprio. A esse respeito: "O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem.

Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior

reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes coma recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminosa e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável.

Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido” (TJSP: Apelação Criminal 1512067-20.2020.8.26.0228; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Barra Funda, 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021). Em relação à dosimetria, ressalto que o réu é tecnicamente primário, pois, apesar de ostentar folha de antecedentes criminais (vide F.A. e certidões constantes em fls.25-27), as condenações anteriores pelo delito de posse de droga para uso próprio não servem para configurar reincidência ou antecedentes criminais que, conquanto seja crime, comporta penas menores, jamais privativas de liberdade, sendo desproporcional produzir um efeito tão rigoroso. Nesse diapasão:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AGRAVANTE AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em relação à agravante do art. 61, I, do Código Penal, ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm decidido ser desproporcional o reconhecimento da reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, cuja inobservância não acarreta a aplicação de pena privativa de liberdade e a constitucionalidade está sendo debatida no STF. 2. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 3. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na quantia e na variedade das substâncias apreendidas – 26,22 de cocaína e 166,32g de crack –, assim como nos demais elementos constantes dos autos, que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento – para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. AgRg no HC 602.724/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual “configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)”. Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois

terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é pouco expressiva: 15 (quinze) porções de "cocaína", acondicionadas em microtubos plásticos, com peso líquido de 6,65g, o réu é tecnicamente primário e não restou provado que ele integra organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de agentes da guarda municipal, sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo.

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 dar epercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento do celular pertencentes ao réu e da importância em dinheiro, a serem revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006).

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem da pena.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não devem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, sem agravantes e presente a atenuante da confissão sendo que a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena

privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu ADRIANO MELO DA SILVA ADRIANO MELO DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Considerando que o réu respondeu ao processo solto e diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado, concedo a interposição de recurso em liberdade.

Decreto o perdimento do celular Samsung e da importância em dinheiro pertencente ao réu, a serem revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006).

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet.

Publique-se e intime(m)-se.

Oportunamente, ao arquivo.

Salto, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA